Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 7ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:( )

Processo nº **0121627-94.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): CONCEICAO DE MARIA DE SOUZA LEAO

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

-

EMENTA: DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA DE FORNECIMENTO SOB A JUSTIFICATIVA DE USO EXPERIMENTAL OU "OFF-LABEL". ILICITUDE DA NEGATIVA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.

- Tratamento oncológico com previsão de cobertura diferenciada em normas (art. 12, I, “c”, e II, “g”, da lei 9.656/98) e jurisprudências pátrias. Precedentes do STJ de dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.

- Medicamento incorporado ao SUS, registrado na ANVISA, uso conforme indicação e prova de necessidade do uso do medicamento para tratamento.

- Diferenciação da prescrição de medicamento *off-label* do uso experimental. Medicamento *off-label* possui comercialização autorizada pela Anvisa e submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância, seu uso não fere as normas sanitárias. O medicamento já foi testado e aprovado pelas autoridades sanitárias, sendo apenas prescrito fora de seu propósito original.

- A operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que se trate de uso "off label", desde que exista comprovação científica de sua eficácia e não haja substituto terapêutico disponível no rol da ANS.

- Indenização por danos morais.

Vistos etc.

Conceição de Maria de Souza Leão, qualificada, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência em face de Bradesco Saúde S/A, igualmente identificada.

Requerendo a gratuidade da justiça e negando interesse em conciliação, expôs ser beneficiária de um plano de saúde empresarial, adimplente com suas obrigações, disse ter sido diagnosticada com neoplasia de vesícula biliar (CID C23), estágio clínico II (T2N0M0), sendo submetida a tratamento cirúrgico oncológico.

Discorreu necessitar de tratamento antineoplásico adjuvante com o medicamento Capecitabina (XELODA), solicitado à ré, mas teve o pedido negado sob a justificativa de que seria tratamento clínico experimental, com base na RN 465 da ANS.

Argumentou ser tal negativa abusiva, pois a eficácia do tratamento é comprovada por estudos científicos e prescrita por seu médico assistente. Alegou, ainda, ser tratamento de cobertura obrigatória pela Lei 9.656/98, que obriga a cobertura de tratamentos antineoplásicos.

Pediu a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja obrigada a fornecer o tratamento de forma urgente e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Deu à causa o valor de R$ 29.650,00.

Acostou documentos.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para *"determinar que a parte ré autorize, no prazo de cinco (05) dias o tratamento indicado no laudo médico de id 186264257 (medicamento Capencitabina (Xeloda®) 500mg—114 compr/ciclo -Tomar 8 comprimidos aos dia (4 pela manhã e 4 comprimidos à noite) por 14 dias por um total de 8 ciclos), até ulterior deliberação do juízo"* (id 186283687).

Contestação (id 188179958) afirmando ter a decisão liminar sido cumprida.

Argumentou que o contrato estava vinculado à Lei 9.656/98 e suas resoluções, e, embora a legislação contemple a cobertura de terapias antineoplásicas orais, essa cobertura estaria sujeita a diretrizes específicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Disse que o medicamento pretendido, Capecitabina (Xeloda®) não tinha indicação em bula para o tratamento da patologia em questão, configurando uso "off-label", uso não coberto contratualmente, nem contemplado no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Destacou haver cláusulas contratuais que excluem expressamente tratamentos experimentais ou com medicamentos não aprovados pela ANVISA para a patologia em questão e citou a Resolução Normativa n.º 465/2021 da ANS, reforçando a ausência de cobertura para o medicamento solicitado.

Argumentou que o medicamento não havia demonstrado aumento significativo na sobrevida dos pacientes em estudos científicos e defendeu a necessidade de observância do rol de procedimentos da ANS como parâmetro para previsibilidade e controle econômico do sistema de saúde suplementar, justificando a negativa de cobertura com base na proteção do mutualismo e sustentabilidade do setor.

Requereu a improcedência dos pedidos formulados pela autora.

Juntou documentos.

Notícia de interposição de agravo de instrumento pela parte ré.

Determinação de intimação da parte autora para réplica e das partes para indicação de possibilidade de composição ou outras provas a produzir (id 188420640).

Réplica sem pedido de provas.

Pedido de julgamento do feito pela parte ré.

É o relatório, passo à decisão.

Ausente pedido de provas, cabe o julgamento da lide.

PLANO DE REFERÊNCIA, ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS E DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT):

A jurisprudência pátria vem sofrendo para estabelecer decisões em casos de cobertura de procedimentos por contratos de assistência à saúde, pois, de um lado, há toda uma gama de direitos estabelecidos em favor da saúde, personalidade e consumidor, havendo, porém, a necessidade de preservação da viabilidade econômica das empresas que ofertam tais pactos e do equilíbrio das contraprestações.

Para tanto, este juízo tem se amparado das normas que lastram ambas as vertentes e das normativas do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), criado pela Lei 9.656/1998, e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, instituída pela Lei 9.961/00, para regulação e fiscalização das atividades que garantam assistência suplementar.

O chamado Plano de Referência foi instituído pelo art. 10 da lei 9.656/98 como aquele com "*cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (...)"* (redação da MP 2.177-44/2001).

Afere-se que mesmo o plano de referência não possui cobertura ilimitada, pois há exceções de cobertura no próprio artigo e em regulamentações da ANS, o que é regulado hoje pela ANS, RN nº 465, de 24/02/2021.

Com relação ao Rol da ANS ser taxativo ou exemplificativo tínhamos divergências entre Turmas do Superior Tribunal de Justiça, pois a 4ª Turma, no REsp 1.733.013/PR, concluiu o que o Rol da ANS seria taxativo, enquanto a 3ª Turma, no RESP 1829583/SP, reafirmou seu entendimento pela não taxatividade do rol mesmo diante dos precedentes da 4ª Turma.

A Agência Nacional de Saúde – ANS, quando da atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, RN nº 465[1], de 24/02/2021, trouxe uma significativa modificação em sua redação, quando, substituindo a redação anterior que falava em listar a cobertura mínima obrigatória, como na RN 428/2017, disse estar a estabelecer a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida, expondo em seu art. 2º que, "*para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos*", o que não constava na RN anterior:

RN nº 465, de 24/02/2021:

"Art. 1º Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998.
§1º Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica.
§2º A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT.
Art. 2º Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde."

RN nº 428, de 07/11/2017:

"Art. 1º Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, e naqueles adaptados conforme a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998."

Assim, apesar de a RN de 2021 acrescentar 69 novas coberturas, ela incluiu em sua redação que "*para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta RN e seus anexos*", estabelecendo sua taxatividade.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, em julgamento de 08/06/2022, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela ANS, desobrigando as operadoras de saúde à cobertura de tratamentos ali não previstos. Foram, não obstante, ali fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, seja imperativo o custeio de procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

No que se refere às exceções, no julgamento do EREsp 1.886.929 foi decidido ser o plano de saúde obrigado a custear tratamento não contido no rol para um paciente com diagnóstico de esquizofrenia, e, no EREsp 1.889.704, foi entendido caber à operadora cobrir tratamento para pessoa com transtorno do espectro autista, porque a ANS já reconhecia a terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do rol de saúde suplementar[2].

O STJ definiu as seguintes teses[3]:

"1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado,

quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS."

Em relação às quatro condicionantes do item "4", a seção citou os enunciados 23, 33 e 97 das Jornadas de Direito em Saúde (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/03/e8661c101b2d80ec95593d03dc1f1d3e.pdf):

> *"ENUNCIADO Nº 23 Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS recomenda-se a consulta, pela via eletrônica e/ou expedição de ofício, a esta agência Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio."*
>
> *"ENUNCIADO Nº 33 Recomenda-se aos magistrados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e aos Advogados a análise dos pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - Conitec para auxiliar a prolação de decisão ou a propositura da ação. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)"*
>
> *"ENUNCIADO Nº 97 As solicitações de terapias alternativas não previstas no rol de procedimentos da ANS, tais como equoterapia, hidroterapia e métodos de tratamento, não são de cobertura e/ou custeio obrigatório às operadoras de saúde se não estiverem respaldadas em Medicina Baseada em Evidência e Plano Terapêutico com Prognóstico de Evolução."*

Ressalto que sobreveio a Lei nº 14.454, de 21/09/2022, que modificou o art. 10 da Lei nº 9.656/1998, entendendo caber exceções ao rol da ANS, nos seguintes termos:

> *"Art. 10.* (https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2022-09-21%3B14454!art2_cpt_alt1_art10) *.....*
>
> *§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. (...)*
>
> *§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*
>
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
>
> *II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."*

À luz da nova legislação, cabível exceção ao rol condicionada a dois elementos: que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde

(Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Após a publicação de tal lei, o Supremo Tribunal Federal, entendeu pelo não conhecimento das ações de controle de constitucionalidade ADPFs 986 e 990 e ADIs 7.088, 7.183 e 7.193, por perda do objeto por causa do advento da Lei n° 14.454/2022.

No entanto, está esse longe de ser assunto pacífico, pois na Terceira Turma do STJ, em 17/11/2022, no I Congresso do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), anunciou que o STJ reabrirá o debate sobre a natureza exemplificativa do rol de procedimento da ANS[4] e a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) propôs, em 11/11/2022, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.265, em face da nova lei, ainda pendente de julgamento pelo STF.

No voto condutor do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, quando do julgamento pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1870834/SP, submetido ao rito dos repetitivos, Tema 1069, em julgado de 13/09/2023, assim consolidou:

> *"Como se verifica, a inovação normativa praticamente positivou os critérios delineados pela Segunda Seção do STJ, tornando o "rol taxativo mitigado" em "rol exemplificativo mitigado".*
>
> *Em outras palavras, a Lei nº 14.454/2022 promoveu alteração na Lei nº 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.*
>
> *Assim, com a edição da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.*
>
> ***Cabe ressaltar que os efeitos práticos do "rol taxativo mitigado" ou do "rol exemplificativo mitigado" serão similares, isto é, tais efeitos ultrapassam eventuais rótulos reducionistas.***
>
> *A respeito, confira-se o **Enunciado nº 109** das Jornadas de Direito da Saúde:*
>
> > *"**Solicitado procedimento ou tratamento médico não previsto no Rol da ANS, cabe verificar, além das condições legais descritas no artigo 10, § 13 da Lei nº 9.656/98: a) se existe, para o tratamento do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol da ANS; b) se não foi indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ou tratamento; c) se há expressa exclusão regulamentar ou legal em relação ao procedimento ou tratamento solicitado; d) se há notas ou pareceres técnicos de órgãos tais como a Conitec e o NatJus que avaliaram tecnicamente a eficácia, acurácia e efetividade do plano terapêutico**." (grifou-se)."*

Assim, entendeu aquela Corte Superior pela equivalência entre os termos *"rol taxativo mitigado"* e *"rol exemplificativo mitigado",* mantendo seu posicionamento.

Por fim, o Fonajus - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para o monitoramento e a resolução das demandas de assistência à saúde, no enunciado n° 109 (15/06/2023), da VI Jornada de Direito da Saúde, dispôs:

> *"Solicitado procedimento ou tratamento médico não previsto no Rol da ANS, cabe verificar, além das condições legais descritas no artigo 10, § 13 da Lei n° 9.656/98: a) se existe, para o tratamento do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol da ANS; b) se não foi indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ou tratamento; c) se há expressa exclusão regulamentar ou legal em relação ao procedimento ou tratamento solicitado; d) se há notas ou pareceres técnicos de órgãos tais como a Conitec e o NatJus que avaliaram tecnicamente a eficácia, acurácia e efetividade do plano terapêutico".*

Ainda exponho outros enunciados do Fonajus - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para orientação no julgamento de demandas de saúde sobre medicina baseada em evidências:

> *ENUNCIADO N° 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019);*
>
> *ENUNCIADO N° 29 Na análise de pedido para concessão de tratamento, medicamento, prótese, órtese e materiais especiais, os juízes deverão considerar se os médicos ou os odontólogos assistentes observaram a eficácia, a efetividade, a segurança e os melhores níveis de evidências científicas existentes. Havendo indício de ilícito civil, criminal ou ético, deverá o juiz oficiar ao Ministério Público e a respectiva entidade de classe do profissional.*
>
> *ENUNCIADO N° 59 As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE.*
>
> *ENUNCIADO N° 89 Deve-se evitar a obstinação terapêutica com tratamentos sem evidências médicas e benefícios, sem custo-utilidade, caracterizados como a relação entre a intervenção e seu respectivo efeito - e que não tragam benefícios e qualidade de vida ao paciente, especialmente nos casos de doenças raras e irreversíveis, recomendando-se a consulta ao gestor de saúde sobre a possibilidade de oferecimento de cuidados paliativos de acordo com a política pública.*
>
> *ENUNCIADO N° 97 As solicitações de terapias alternativas não previstas no rol de procedimentos da ANS, tais como equoterapia, hidroterapia e métodos de tratamento, não são de cobertura e/ou custeio obrigatório às operadoras de saúde se não estiverem respaldadas em Medicina Baseada em Evidência e Plano Terapêutico com Prognóstico de Evolução.*
>
> *ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)*

CASO CONCRETO – MEDICAMENTO ONCOLÓGICO:

Ressalto que o medicamento oncológico de uso domiciliar merece cobertura em qualquer forma de administração, conforme art. 12, I, "c", e II, "g", da lei 9.656/98, que estabeleceu tratamento diferenciado:

-

> *"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)* (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...)*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)*

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm#art2) *(Vigência)* (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm#art3)

II - quando incluir internação hospitalar: (...)

g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm#art2)*".*

O PARECER TÉCNICO Nº 29/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018[5], que trata dos medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (art. 20, §1º, VI, da RN 428, de 2017), diz ser obrigatória a cobertura para:

"a) Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 21, inciso XI, da RN nº 428, de 2017), respeitadas as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RN nº 428, de 2017; e

b) Medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, obedecidas as exigências previstas nos normativos vigentes da Anvisa e nas alíneas "d" e "g", do inciso II, do artigo 12, da Lei nº 9.656, de 1998 c/c art. 14, da RN nº 428, de 2017."

O PARECER TÉCNICO Nº 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019[6], que trata da cobertura de o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar oncológicos:

"b) Medicamentos utilizados em quimioterapia oncológica ambulatorial que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde. Abrangem, conforme o art. 21, inciso X, da RN nº 428/2017:

b.1) medicamentos antineoplásicos empregados na quimioterapia oncológica ambulatorial, isto é, medicamentos para tratamento do câncer;

b.2) medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento do câncer; e

b.3) medicamentos adjuvantes, ou seja, os medicamentos empregados de forma associada aos quimioterápicos citostáticos com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento.

c) Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e medicamentos adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 12, inciso I, alínea "c", da Lei nº 9.656, de 1998, c/c art. 21, inciso XI, da RN nº 428/2017), respeitadas as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RN nº 428/2017."

A atenção diferenciada de hipóteses de tratamento oncológico é regra na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

-

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. COBERTURA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

*1. **A ja jurisprudência desta Corte reconhece que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante quando se tratar da análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.** 2. Em relação à revisão dos honorários sucumbenciais, convém ressaltar que, de acordo com a orientação deste Tribunal de Uniformização, em virtude do quantitativo da verba honorária decorrer de uma análise específica dos fatos ocorridos*

*durante a marcha processual, na qual o julgador avalia o trabalho desenvolvido pelo patrono e a complexidade da causa, a fim de fixar o percentual que considera correto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça revisar a quantia estabelecida, exceto quando constatada sua manifesta insignificância ou excessividade apta a afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no REsp 1914870 / SP, **RELATOR** Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), T3 - TERCEIRA TURMA, j. 20/03/2023, DJe 22/03/2023)."*

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE RETO ALTO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
*1. **Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.***
*2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 2004990/SP, **RELATORA** Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023)."*

*"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CÂNCER. RECUSA. **ROL** DE PROCEDIMENTOS DA **ANS**. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.*

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

*2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no **rol** de procedimentos da **ANS**.*

*3. **No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS** (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).*

4. No caso, o Tribunal distrital consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela beneficiária. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.º 7 do STJ.

> *5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.*

> *6. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1987435/DF, Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j, 06/03/2023, DJe 09/03/2023)."* (grifos para destacar)

-

A tese da parte ré de caber aqui atenção ao Recurso Repetitivo – IRC – Tema: 106 do STJ, por ser uso do medicamento de caráter experimental, não merece atenção, pois, primeiramente, ali se tratou de obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o que não se aplica. Essa foi a tese firmada:

> ***"Tese Firmada:***
>
> *A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:*
> *i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
>
> *ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
> *iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." (Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).*

<u>Em segundo lugar, cabe ser feita a diferenciação da prescrição de medicamento *off-label* do uso experimental</u>, pois apenas nesse não há garantia e segurança previamente estabelecidos com relação à posologia e seus efeitos no corpo humano.

A prescrição *off-label* é a indicação de medicamento que tem comercialização autorizada pela Anvisa e foi submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância. Seu uso não fere as normas sanitárias. O medicamento já foi testado e aprovado pelas autoridades sanitárias, sendo apenas prescrito fora de seu propósito original.

Na maioria das vezes o medicamento apenas ainda não foi aprovado para determinada terapêutica no país, já tendo a referida indicação no exterior e muitas vezes tais indicações nunca constarão na bula por falta de ensaios clínicos necessários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende caber cobertura pelo plano de saúde à prescrição *off-label* em casos concretos justificados:

> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento do medicamento succinato de ribociclibe (Kisqali), necessário para tratamento oncológico. 2. <u>Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira</u>*

Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário 3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes. 4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2030294 MS 2021/0373400-7, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)" (grifos para destacar).

"RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO CLÍNICO OU CIRÚRGICO EXPERIMENTAL E MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. USO OFF LABEL. POSSIBILIDADE, EM SITUAÇÕES PONTUAIS. CONFUSÃO COM TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DESCABIMENTO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA, A RESPALDAR O USO. NECESSIDADE.

1. Por um lado, o art. 10, incisos I, V e IX, da Lei n. 9.656/1998, testilhando com a fundamentação da decisão recorrida, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. Por outro lado, no tratamento experimental, o intuito da pesquisa clínica não é propriamente tratar, mas alcançar resultado eficaz e apto ao avanço das técnicas terapêuticas atualmente empregadas, ocorrendo em benefício do pesquisador e do patrocinador da pesquisa.

2. O art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998, por tratar de questão atinente ao exercício profissional da medicina, deve ser interpretado em harmonia com o art. 7º, caput, da Lei n. 12.842/2013, que estabelece que se compreende entre as competências da autarquia Conselho Federal de Medicina - CFM editar normas "para definir o caráter experimental de procedimentos em Medicina", autorizando ou vedando sua prática pelos médicos.

3. Nessa linha, consoante deliberação do CFM, o uso off label justifica-se em situações específicas e casuísticas e ocorre por indicação médica pontual, sob o risco do profissional que indicou. É considerado como hipótese em que "o medicamento/material médico é usado em não conformidade com as orientações da bula, incluindo a administração de formulações extemporâneas ou de doses elaboradas a partir de especialidades farmacêuticas registradas; indicações e posologias não usuais; administração do medicamento por via diferente da preconizada; administração em faixas etárias para as quais o medicamento não foi testado; e indicação terapêutica diferente da aprovada para o medicamento/material".

4. Havendo evidências científicas que respaldem a prescrição, é universalmente admitido e corriqueiro o uso off label de medicamento, por ser fármaco devidamente registrado na Anvisa, aprovado em ensaios clínicos, submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância e produzido sob controle estatal, apenas não aprovado para determinada terapêutica.

5. Conforme propõe o Enunciado n. 15 da I Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, devem as prescrições médicas consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, da posologia, do modo de administração, do período de tempo do tratamento "e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica". 6. Assim, como a questão exige conhecimento técnico e, no mais das vezes, subjacente divergência entre profissionais da saúde (médico assistente do beneficiário e médico-perito da operadora do plano), para propiciar a prolação de decisão racionalmente fundamentada, na linha do que propugna o Enunciado n. 31 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, o magistrado deve "obter

informações do Núcleo de Apoio Técnico ou Câmara Técnica e, na sua ausência, de outros serviços de atendimento especializado, tais como instituições universitárias, associações profissionais, etc".

7. A prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal, e nem mesmo a recorrente afirma que a utilização do fármaco traz algum risco de dano à saúde da autora ou que seja ineficaz para o tratamento da enfermidade que a acomete. Portanto, e pela ausência de pedido de cassação da sentença para solicitação de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e/ou produção de prova pericial para demonstração da inexistência de evidência científica (clínica) a respaldar a prescrição do medicamento, é de rigor a confirmação da decisão recorrida, ainda que por fundamento diverso.

8. Recurso especial não provido." (REsp 1729566/SP, RELATOR Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 04/10/2018, DJe 30/10/2018).

*"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. **É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que se trate da hipótese de tratamento experimental ou off label.** 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1989283 RN 2022/0050242-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)"* (grifos para destacar).

O pedido foi de fornecimento de XELODA® (Capecitabina) para tratamento oncológico, tendo o PARECER TÉCNICO nº 23/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016 trazido a cobertura do medicamento para câncer colorretal metastático, gástrico e mama, o que é reafirmado pelo PARECER TÉCNICO nº 27/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018:

"PARECER TÉCNICO Nº 23/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016: De acordo com a DUT para o procedimento TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER, o medicamento Capecitabina tem indicação nos seguintes casos:
a) Primeira linha em câncer colorretal metastático;
b) Adjuvante para pacientes em estágio II com critério de alto risco ou Dukes C (estágio III) de câncer colorretal, submetidos à ressecção completa de tumor primário;
c) Câncer gástrico em estágio avançado, desde que associado com compostos de platina, como a cisplatina ou a oxaliplatina; e
d) Câncer de mama metastático, após falha de antraciclina ou taxano, ou em face de contraindicação para estas medicações."

Atendo-me ao fato sob foco, verifico no laudo de id 186264257 constar:

"Paciente com o diagnóstico de neoplasia de vesícula biliar (CID 23) estágio clínico II (T2NOMO) submetida a ressecção cirúrgica oncológica, tem indicação de tratamento oncológico adjuvante com Capencitabina (XELODA®) por 8 ciclos, conforme a prescrição abaixo. Com objetivo de evitar recidivas neoplásicas e. consequentemente, aumentar sobrevida da paciente. O tratamento adjuvante (complementar a cirurgia) com a droga Capencitabina, para a situação clínica da paciente, tem comprovada eficácia baseada em vasta evidência científicas baseado no estudo BilCAP, assim sendo, não se trata de uma

conduta terapêutica experimental. Saliento também que o tratamento está sendo prescrito de acordo com orientações de diretrizes de diversas entidades nacionais e internacionais de referência em oncologia- MOC (Manual de Oncologia Cínica), NCCN (National Compreensive Cancer Network), ESMO (European Society for Medical Oncology) e Protocolos de Oncologia do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro (vide em anexo). Frisa-se que para o caso da paciente em questão, não consta do Rol da ANS outro tratamento com a mesma eficácia do tratamento com a droga Capencitabina (XELODA®). O atraso no início do tratamento poderá levar a diminuição de eficácia terapêutica, consequentemente diminuição da sobrevida da paciente, aumentando as chances de recidiva neoplásica. Deve, portanto, ser iniciado com a máxima urgência. Esquema de tratamento: 1) Capencitabina (Xeloda®) 500mg—114 compr/ciclo -Tomar 8 comprimidos aos dia (4 pela manha e 4 comprimidos a noite) por 14 dias por um total de 8 ciclos" (id 186264257).

A parte autora relata e prova ter sido já submetida a cirurgia e a tratamentos com outros fármacos, mas sem sucesso.

Dessa forma, há obrigatoriedade de cobertura para o fornecimento do medicamento pois observadas as condições estipuladas na DUT acima exposta, tal como constante do laudo de id 186264257, sendo hipótese de tratamento contemplada, e diante do histórico acima narrado de diversos tratamentos desde a descoberta do câncer.

O médico assistente, diante da evolução da moléstia, prescreveu o uso de XELODA® (Capecitabina) sendo essa a indicação clínica que, diante da hipótese dos autos, é a única a lhe conferir chances de melhora, cabendo a excepcionalidade ao caso, diante de tudo que já foi aqui exposto.

Inexiste, dessa forma, desatenção ao julgado do Recurso Repetitivo IRC Tema: 106 do STJ.

Assim, a parte autora preenche os requisitos, cabendo cobertura integral do medicamento.

DANO MORAL:

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, o conceito de dano moral foi construído pela doutrina e jurisprudência, mas com base na legislação. A CF vincula a configuração ao dano moral a uma lesão relevante a direitos da personalidade e afirma que, apesar de não haver conceito de dano moral, há normativação, prescindindo de lesão relevante dos direitos subjetivos da pessoa humana.

O STJ chama atenção do fato de que o dano moral não é a dor ou o sofrimento, esses são os efeitos ou reflexos do dano, não se condiciona a configuração do dano algo subjetivo e impossível de prova, já que não se pode entrar na emoção daquela pessoa, havendo que ser provada lesão relevante a direito da personalidade.

Na responsabilidade civil se requer prova da conduta, do dano e o nexo entre ele – e se for o caso de responsabilidade subjetiva, culpa ou dolo – mas há hipóteses em que o dano é presumido, temos dano moral *in re ipsa* – pois, comprovados os fatos, presume-se que daquelas hipóteses fáticas decorre dano moral. O dano há que ser decorrente do fato e esses fatos são suficiente para gerar lesão relevante a direito de personalidade de qualquer pessoa, prescindindo sua demonstração em juízo (*in re ipsa)*.

Nesse sentido a precisa doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

“Uma das mais relevantes questões nas ações indenizatórias é a prova do dano, por ser ele, como visto, requisito indispensável para a reparação. Nesse sentido adverte Agostinho Alvim: "Grande número de vezes o credor não consegue cobrir-se dos prejuízos totais, não por causa da lei, que lhe dá tudo, mas por causa do rigor da prova exigida." Completa o Mestre: "Sempre se reconheceu haver situações difíceis e provas quase que impossíveis de produzir com precisão, dada a natureza dos fatos. O princípio da reparação do dano exige que se tenha em vista todas as circunstâncias que rodeiam o caso, não sendo possível traçar, a priori, regras fixas, que invariavelmente se ajustam a todas as hipóteses." E como, de regra, não se presume o dano, esta é uma questão que deve merecer redobrada atenção de quem busca uma indenização em juízo.

Cumpre, então, lembrar que uma coisa é a prova do dano, do fato lesivo, da efetiva violação do dever jurídico, e outra é a prova do valor da indenização. Tanto assim que a efetividade do dano e o cálculo da indenização podem ser apreciados em duas fases distintas. Na primeira, prova-se a existência do dano, a efetiva ocorrência do fato lesivo e a responsabilidade de seu causador (an debeatur); na segunda, busca-se fixar a extensão do dano, a sua quantificação, o valor da indenização (quantum debeatur). Isso se torna mais evidente nos casos de interesses ou direitos individuais homogêneos, os que decorrem de origem comum (CDC, art. 81, III). Na ação coletiva prova-se o fato lesivo comum (an debeatur), cabendo depois, a cada vítima, promover a execução, na qual deverá ser apurado o valor da indenização de cada uma (quantum debeatur).

Como se prova a existência do dano? Ora, se dano é lesão de um bem ou interesse juridicamente tutelado (e aí está a importância dos conceitos), prova-se o dano provando-se a ocorrência do fato lesivo (v. g., o acidente, a morte do ente familiar, o fato do produto ou do serviço, o fato ofensivo à honra etc.) por qualquer meio de prova em juízo admitido - documental, testemunhal, pericial etc. Tanto o dano patrimonial como o dano extrapatrimonial exigem a prova do fato lesivo. Por isso se diz que dano certo é aquele cuja existência acha-se provada, de tal modo que não pairam dúvidas quanto à sua ocorrência.

Não basta, portanto, simplesmente alegar a existência de um fato lesivo sem fazer prova de sua efetiva ocorrência, mesmo porque não cabe à contraparte fazer prova de fato negativo.

Sem prova efetiva do fato lesivo e da responsabilidade do agente, repita-se, a ação indenizatória estará irremediavelmente prejudicada, mas, demonstrada a existência do fato danoso, resta ao prejudicado o direito à indenização. Provado o fato lesivo a bem patrimonial ou moral, que ficará o dano estará ínsito na própria ofensa, decorrerá da gravidade do ilícito em si. O pendente de apuração será o valor da indenização, o quantum debeatur. Esse é o sentido do entendimento da doutrina e da jurisprudência no que respeita à existência do dano moral in re ipsa. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação

de ordem pecuniária ao lesado. Compreende-se que assim seja porque a lesão ou gravame no plano moral nem sempre se materializa no mundo físico, por essa razão prescindindo de provas. Mas o fato gravoso e os reflexos que a sua potencialidade ofensiva irradia terão que ser comprovados.

Em outras palavras, só se justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado quando há efetiva ocorrência de fato grave e ofensivo. O dano moral nesse caso existirá in re ipsa, decorrerá inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto estará demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras da experiência comum. Assim, por exemplo, provada a perda de um filho, do cônjuge, ou de outro ente querido, não há que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio fato de acordo com as regras de experiência comum; provado que a vítima teve o seu nome aviltado, ou a sua imagem vilipendiada, nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral.

A Terceira Turma do STJ deu correta aplicação a esta questão: "Quanto ao dano moral, em si mesmo, não há falar em prova; o que se deve provar é o fato que gerou a dor, o sofrimento. Provado o fato, impõe-se o dano in re ipsa". No mesmo sentido decidiu novamente a Terceira Turma: "Nos casos de protesto de título ou inscrição irregular em cadastros de

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." Por último, a Quarta Turma: "Inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito. Dano moral presumido. Desnecessidade de comprovação. Obrigação de indenizar".

Como bem observa Anderson Schreiber, "Nestas situações, diz-se com frequência que o juiz recorre a presunções de dano. Não parece ser tanto este o caso. O juiz não observa simplesmente a notícia e a partir dela extrai a ilação de que tenha ou não causado dano à honra da vítima. Ao contrário, o juiz observa a notícia e verifica, objetiva e concretamente, se sua veiculação lesa a honra da vítima, perquirindo, por exemplo, se a notícia emprega contra o autor da demanda expressões difamatórias, se alude ao seu caráter, se lhe dirige ofensa pessoal. Eis como se prova a lesão e, portanto, o dano. Se a vítima se lamentará do fato, se sofrerá com ele, ou se lhe demonstrará indiferença são questões subjetivas que podem, no máximo, servir de indícios da intensidade do dano para fins de sua quantificação, mas não interferem tecnicamente na sua reparação."

(...)

Por fim, a lição de Xisto Tiago de Medeiros Neto: "A certeza do dano emerge objetiva e diretamente do evento causador (ipso facto), o que se faz compreensível nos domínios da lógica. que não se pode pretender provar eventuais efeitos da violação (aspectos como insegurança, transtorno ou abalo coletivo), uma vez que estes são consequências que têm realidade apreendida a partir do senso comum".

Mas, lembre-se, esse entendimento não se aplica a qualquer ato ilícito. Não cabe falar em dano moral in re ipsa quando o fato narrado está no contexto de meros dissabores, sem qualquer agressão à dignidade ou ofensa a atributo da personalidade. Para se presumir o dano moral pela simples comprovação do fato, esse fato tem que ter a capacidade de causar dano, o que se apura por um juízo de experiência. Nesse sentido também está assentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

> "RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE CADASTRO DE CORRENTISTAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
>
> Depreende-se dessa síntese doutrinária e jurisprudencial que o dano moral, embora prescinda de prova, o que se convencionou chamar de dano in re ipsa, deve ser aferido em face do caso concreto e não em tese. Será sempre indispensável a efetiva ocorrência de fato realmente ofensivo a bens e valores da personalidade para se admitir a existência do dano in re ipsa.
>
> I - Para se presumir o dano moral pela simples comprovação do ato ilícito, esse ato deve ser objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos.
>
> II - Hipótese em que, não obstante ser incontroversa a ocorrência do ato ilícito, não restou comprovado que de tal ato adveio qualquer consequência capaz de configurar o dano moral que se pretende ver reparado.

Depreende-se dessa síntese doutrinária e jurisprudencial que o dano moral, embora prescinda de prova, o que se convencionou chamar de dano in re ipsa, deve ser aferido em face do caso concreto e não em tese. Será sempre indispensável a efetiva ocorrência de fato realmente ofensivo a bens e valores da personalidade para se admitir a existência do dano in re ipsa."[7]

Especificamente ao caso, coloco que a jurisprudência do STJ vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada[8].

Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco observa restar configurado o dano moral, pelo sofrimento e abalo psíquico-econômico experimentado pelo paciente, ao ser desprotegido pelo plano em momento de grande fragilidade física e emocional[9].

No tocante ao valor da indenização, entendo que conferir valor ao dano moral é tarefa árdua, eis que não se pode valorar a dor da agressão ao direito de personalidade imposta a alguém, assim, a jurisprudência pátria tem fixado parâmetros de modo a se ter uma compensação amenizadora, não irrisória e nem exacerbada.

Entendo, porém, que o valor da indenização deve ser adequado às peculiaridades do fato em questão, atendendo à repercussão do dano na esfera íntima do ofendido, às circunstâncias do fato em si, sua extensão.

No caso sob foco, ressaltando os fatos acima já narrados, e levando em consideração, outrossim, o potencial econômico-social do ofensor, de forma a inibir tal comportamento, ou seja, verdadeiro *desestímulo* a ponto de demovê-lo de novas práticas lesivas da mesma espécie ou diversa, tendo caráter não punitivo, mas pedagógico.

Adoto esse entendimento, ressalto, sob o exemplo do Superior Tribunal de Justiça, quando em seus julgados em que ressalta o caráter pedagógico do dano moral, visando exatamente o que dito acima, inibir outros comportamentos lesivos de igual forma (*EREsp 748868/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 25/03/2009, DJe 06/04/2009 / Esp 910794/RJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, j. 21/10/2008, DJe 04/12/2008 - REsp 763531 / RJ SEGUNDA TURMA Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS25/03/2008 DJe 15/04/2008*).

Assim, diante de tudo que foi acima exposto, fixo em R$ 10.000,00 o valor a ser indenizado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com base na Lei nº 9.656/98, art. 10, I, c e II, g; Lei nº 14.454/2022; CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 487, I, julgo procedente o pedido para:

a) confirmar a tutela de id 186283687, que ordenou à ré autorização ao tratamento indicado no laudo médico de id 186264257 (medicamento Capencitabina (Xeloda®) 500mg—114 compr/ciclo -Tomar 8 comprimidos ao dia (4 pela manhã e 4 comprimidos à noite) por 14 dias por um total de 8 ciclos);

b) condenar a parte demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária a contar da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ e do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora de acordo com a SELIC, contados da citação (CC, art. 405 e CPC, art. 240), deduzido o índice de atualização monetária quando houver sobreposição, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil;

c) condenar a parte demandada ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador adversário, estes fixados em 10% do valor total da condenação (valor do tratamento orçado na inicial – R$ 19.650,00 – sio-somado ao valor de condenação por danos morais), com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se o pagamento integral das custas processuais da fase de conhecimento e arquivem-se os autos.

Em não tendo ocorrido pagamento das custas, intime-se a parte sucumbente para efetuar o pagamento das custas processuais, no prazo de quinze dias, **sob as penalidades da lei.**

Em não havendo manifestação, à secretaria para efetuar os cálculos dos valores anteriormente mencionados e, em seguida, oficie-se à Procuradoria do Estado, para as devidas providências legais, e à Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Comitê Gestor de Arrecadação, nos termos dos Provimentos nº 007/2019 - CM, de 10 de outubro de 2019, e nº 003/2022-CM, de 10 de março de 2022.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife, 13 de janeiro de 2025.

IASMINA ROCHA

Juíza de Direito

---

[1] Disponível em: <http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NDAzMw==#ANEXOS (http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NDAzMw==#ANEXOS)> Acesso em 12/03/2021.

[2] https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx)> Acesso em 29/06/2022.

[3] https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx)> Acesso em 29/06/2022.

[4] Disponível em: https://www.conjur.com.br/2022-nov-17/turma-stj-retomara-debate-rol-ans-lei (https://www.conjur.com.br/2022-nov-17/turma-stj-retomara-debate-rol-ans-lei)>. Acesso em 21/11/2022.

[5] http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_PARECER_29-2018_MEDICAMENTOS%20PARA%20TRATAMENTO%20DOMICILIAR_VERSO%20FINAL_28122017.pdf> ACESSO EM 09/03/2020.

[6] http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_parecer_2019_21.pdf> acesso em 10/03/2020

[7]CAVALIERI FILHO, Sergio. **Programa de Responsabilidade Civil.** 16ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2023, págs. 113/115.

[8] STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021; AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020; REsp 986.947/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11.03.2008, DJ 26.03.2008 p. 1

[9] TJ-PE - AC: 00321003920218172001, Relator: JOAO JOSE ROCHA TARGINO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)); TJ-PE - AC: 5366010 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 30/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019; AC 115577-1 – Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio – DJPE 13.06.2007

Assinado eletronicamente por: IASMINA ROCHA
13/01/2025 10:08:45
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 192428920

25011310084535500000187594987

IMPRIMIR GERAR PDF